

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 772/2550     
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     
 โจทก์  
 บังคา นาซีโอแนล เดล ลาโวโร เอสพีเอ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 6, มาตรา 224 วรรคหนึ่ง, มาตรา 359 วรรคสอง, มาตรา 361

พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 มาตรา 13

จำเลยขอให้โจทก์ออกหนังสือประกันการปฏิบัติตามสัญญาของกิจการร่วมค้า อ. ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยจำเลยยอมประกันช่วงผูกพันตน ด้วยเงื่อนไขทำนองเดียวกันต่อโจทก์ (Instructions and Counter Guarantee)

โจทก์ออกหนังสือประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Letter of Guarantee, Performance Security) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว ต่อมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีหนังสือแจ้งโจทก์ว่าได้บอกเลิกสัญญากับกิจการร่วมค้า อ. เพราะเหตุผิดสัญญา และขอให้โจทก์ชำระเงินตามหนังสือประกันดังกล่าว การที่โจทก์แจ้งให้จำเลยทราบและเรียกให้จำเลยชำระเงินจึงเป็นการปฏิบัติไปตามข้อตกลงในสัญญาประกันช่วงระหว่างโจทก์จำเลย จำเลยรับทราบแล้วแจ้งกลับมายังโจทก์เพียงว่า ศาลในประเทศอิตาลีมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ และกิจการร่วมค้า อ. แจ้งจำเลยว่าจะเชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้ร่วมเจรจารับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ขอให้โจทก์หยุดชำระเงินไว้ก่อน นั้น ทั้งสองเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุผลที่จะปลดเปลื้องความรับผิดชอบของโจทก์ที่มีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือปลดเปลื้องจำเลยจากความรับ

ผิดที่มีต่อโจทก์ตามสัญญาประกันช่วงแต่อย่างใด เพราะเป็นข้ออ้างที่ขัดกับข้อความ  
รับผิดตามหนังสือประกันและสัญญาประกันช่วงนั่นเอง การที่โจทก์ไม่พิจารณาคำ  
ทักท้วงดังกล่าวหรือสืบหาข้อเท็จจริงตามข้ออ้างของจำเลยจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่  
สุจริตแต่อย่างใด โจทก์ชำระเงินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อถูก  
เรียกให้ชำระตามเงื่อนไขและภาระผูกพันในหนังสือประกันย่อมเป็นการกระทำโดย  
ชอบแล้ว มิใช่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เมื่อโจทก์เรียกให้จำเลยชำระหนี้ตาม  
สัญญาประกันช่วง จำเลยจึงต้องรับผิดชำระหนี้ตามจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์

โจทก์ทวงถามเป็นหนังสือไปยังจำเลยโดยการส่งโทรพิมพ์ (First Written  
Demand by Tested Telex) ตรงตามเงื่อนไขในสัญญาประกันช่วงแล้ว จำเลยย่อม  
มีหน้าที่ชำระเงินให้แก่โจทก์ตามจำนวนที่ระบุทันที เมื่อจำเลยไม่ชำระจึงตกเป็นผู้  
ผิดนัด เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าคู่สัญญาแสดงเจตนากำหนดเรื่องอัตราดอกเบี้ยกัน  
ไว้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิกำหนดอัตราดอกเบี้ยฝ่ายเดียว คงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยใน  
ระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง

จำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลในประเทศอิตาลีทำคำเสนอทางโทรพิมพ์มายังโจทก์ซึ่ง  
เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โจทก์ไม่ได้ตกลงรับว่าจะออกหนังสือประกันให้ตามที่  
จำเลยเสนอมาในทันที แต่กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในคำสนองว่าโจทก์จะออกหนังสือ  
ประกันให้ก็ต่อเมื่อจำเลยยอมประกันช่วงแก่โจทก์ว่าจำเลยจะชดใช้เงินตามจำนวนที่  
โจทก์ชำระให้แก่ผู้รับประโยชน์คืนให้แก่โจทก์ เมื่อคำสนองดังกล่าวมีข้อความเพิ่ม  
เติม มีข้อจำกัด หรือมีข้อแก้ไขอย่างอื่นประกอบด้วย จึงถือว่าเป็นคำบอกปัดไม่รับ  
ทั้งมีผลเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 359 วรรคสอง แม้จำเลยได้รับ  
โทรพิมพ์ดังกล่าวแล้ว สัญญาขอให้ออกหนังสือประกันและสัญญาประกันช่วงระหว่าง  
โจทก์จำเลยก็ยังไม่เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีดังที่จำเลยอ้างแต่อย่างใดไม่ เมื่อจำเลย  
มีโทรพิมพ์ ตอบกลับมายังโจทก์ว่าจำเลยให้อำนาจโจทก์ระบุข้อความรับผิดในการ

ประกันช่วงดังกล่าวได้ โดยมีได้มีข้อความเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขอย่างใดอีก โทรมพ์ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำสนองของจำเลย ดังนี้ สัญญาขอให้ออกหนังสือประกันและสัญญาประกันช่วงระหว่างโจทก์จำเลยย่อมเกิดขึ้นทันทีที่โจทก์ได้รับโทรมพ์ดังกล่าวที่ประเทศไทยตาม ป.พ.พ. มาตรา 361 วรรคแรกจึงต้องใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่สัญญาเกิดคือกฎหมายไทยบังคับและต้องฟ้องคดีต่อศาลไทย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 มาตรา 13

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 88,244,307.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีจากต้นเงิน 65,840,499.52 บาท และจำนวน 5,492,837.48 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีจากต้นเงิน 4,098,294.52 ดอลลาร์สหรัฐ นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความให้จำเลย 30,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกว่า โจทก์ชำระเงินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขและภาระผูกพันในหนังสือประกันโดยชอบและโดยสุจริตหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า เหตุที่โจทก์ชำระเงินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่าได้บอกเลิกสัญญาเกี่ยวกับกิจการร่วมค้าอีอีโก เอสพีเอ และขอให้โจทก์ชำระเงินตามหนังสือประกันการปฏิบัติตามสัญญา โจทก์ในฐานะผู้ออกหนังสือประกันจึงต้องรับผิดชอบตามภาระในสัญญาประกัน ซึ่งก่อนที่โจทก์จะชำระเงินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โจทก์ได้มีโทรพิมพ์แจ้งไปยังจำเลยเกี่ยวกับการจะชำระเงินดังกล่าวแล้วจำเลยแจ้งกลับมายังโจทก์ว่าจำเลยไม่สามารถชำระเงินให้แก่โจทก์ได้ เพราะศาลในประเทศอิตาลีมีคำสั่งให้จำเลยงดชำระเงินแก่โจทก์ไว้ก่อนโจทก์จึงได้ชำระเงินให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปโดยชอบและโดยสุจริตนั้น เห็นว่าตามหนังสือสัญญาประกันการปฏิบัติตามสัญญา 8 ฉบับ โจทก์มีความผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัดเมื่อถูกทวงถามโดยไม่อาจอ้างเหตุใด ๆ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกิจการร่วมค้าอีอีโก เอสพีเอ ขึ้นปลดเปลื้องความรับผิดได้ ซึ่งข้อความในหนังสือประกันดังกล่าวเป็นไปตามที่โจทก์จำเลยตกลงกัน จำเลยจึงย่อมทราบดีว่าเมื่อโจทก์ออกหนังสือประกันที่มีข้อความเช่นนั้นให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วโจทก์จะมีความรับผิดชอบต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพราะจำเลยเป็นผู้ที่กำหนดเงื่อนไขความรับผิดเคร่งครัดเช่นนั้นให้โจทก์กระทำตาม ทั้งนี้จำเลยเองก็ตกลงผูกพันตนโดยเคร่งครัดในการประกันช่วงด้วยเงื่อนไขทำนองเดียวกันตอบแทนโจทก์ โจทก์ชำระเงินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปหลังจากได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่ากิจการร่วมค้าอีอีโกเอสพีเอ ผิดสัญญาและถูกบอกเลิกสัญญาแล้ว จึงเป็นการปฏิบัติตามการชำระหนี้ตามความผูกพันในหนังสือประกันนั่นเอง การที่โจทก์แจ้งให้จำเลยทราบและเรียกให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาประกันช่วงก็เป็นการปฏิบัติไปตามข้อตกลงในสัญญาประกันช่วงระหว่างโจทก์จำเลย จำเลยรับทราบแล้วแจ้งกลับมายังโจทก์เพียงว่า ศาลในประเทศอิตาลีมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ และกิจการร่วมค้าอีอีโก เอสพีเอ แจ้งจำเลยว่าจะเชิญ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้ร่วมเจรจารับข้อพิพาทด้วยกระบวนการ  
อนุญาโตตุลาการขอให้โจทก์หยุดชำระเงินไว้ก่อนนั้น เหตุผลที่อ้างดังกล่าวเป็นการ  
กล่าวอ้างเหตุขัดข้องของจำเลยเองประการหนึ่ง กับเหตุขัดข้องตามสัญญาการจัด  
มลภาวะทางอากาศระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับการร่วมค้าอีอีโก  
เอสพีเอ อีกประการหนึ่ง ซึ่งทั้งสองเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุผลที่จะปลดเปลื้องความรับ  
ผิดของโจทก์ที่มีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามหนังสือประกันการปฏิบัติ  
ตามสัญญา หรือปลดเปลื้องจำเลยจากความรับผิดของจำเลยที่มีต่อโจทก์ตามสัญญา  
ประกันช่วงแต่อย่างใด เพราะเป็นข้ออ้างที่ขัดกับข้อความรับผิดตามหนังสือประกัน  
และสัญญาประกันช่วงที่ว่า "...โจทก์ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะประกันชนิด  
เพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ไม่ใช่เพียงแต่เป็นการค้ำประกันเท่านั้น ใน  
การชำระเงินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทันทีที่ถูกเรียกให้ชำระโดยจะ  
ไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน..."  
เมื่อเงื่อนไขดังกล่าวผูกพันโจทก์ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่าง  
เคร่งครัด เงื่อนไขทำนองเดียวกันนั้นก็ยอมผูกพันจำเลยต่อโจทก์อย่างเคร่งครัดด้วย  
เช่นกัน และเนื้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นเจตนาของคู่สัญญาว่าประสงค์ที่จะแยก  
ความรับผิดของหนังสือประกันและสัญญาประกันช่วงออกจากความรับผิดสัญญา  
ประธานหรือสัญญาอื่น ๆ โดยให้พิเคราะห์แต่การปฏิบัติตามเงื่อนไขเท่าที่ปรากฏใน  
หนังสือประกันและสัญญาประกันช่วงเท่านั้น ดังนั้น ไม่ว่าความจริงจะเป็นไปตาม  
เหตุผลที่จำเลยอ้างมาหรือไม่ ก็ไม่ทำให้โจทก์หลุดพ้นจากหนี้ที่มีต่อการไฟฟ้าฝ่าย  
ผลิตแห่งประเทศไทยตามหนังสือประกัน ทั้งไม่ทำให้จำเลยหลุดพ้นจากความรับผิด  
ต่อโจทก์ตามสัญญาประกันช่วงได้ การที่โจทก์ไม่พิจารณาคำหักท้วงดังกล่าวหรือ  
สืบหาข้อเท็จจริงตามเหตุผลที่จำเลยอ้างมาจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่สุจริตแต่อย่าง  
ใดโจทก์ชำระเงินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อถูกเรียกร้องให้ชำระ  
ตามเงื่อนไขและภาระผูกพันในหนังสือประกันยอมเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว มิใช่

เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เมื่อโจทก์มีโทรพิมพ์เรียกให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาประกันช่วง จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยยจากจำเลยเพียงใด ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีหนังสือทวงถามมาถึงโจทก์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540 ต่อมาวันที่ 31 มกราคม 2540 โจทก์แจ้งเรื่องดังกล่าวทางโทรพิมพ์เรียกให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามสัญญาประกันช่วง ถือว่าโจทก์ได้ทวงถามเป็นหนังสือไปยังจำเลยโดยการส่งทางโทรพิมพ์ (First Written Demand by Tested Telex) ตรงตามเงื่อนไขในสัญญาประกันช่วงแล้ว จำเลยย่อมมีหน้าที่ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุทันที เมื่อจำเลยไม่ชำระจึงตกเป็นผู้ผิดนัด แต่ที่โจทก์อ้างว่า ขณะที่โจทก์ชำระเงินให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โจทก์ประกาศอัตราดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 18 ต่อปี เมื่อโจทก์มีหนังสือทวงถามไปยังจำเลย จำเลยมิได้โต้แย้งเรื่องอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิติดดอกเบี้ยยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2541 อันเป็นวันที่โจทก์ชำระเงินให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปนั้น เห็นว่า ตามสัญญาประกันช่วงระหว่างโจทก์จำเลยไม่ปรากฏว่ามีการตกลงเรื่องอัตราดอกเบี้ยไว้แต่อย่างใด ทั้งภายหลังเมื่อโจทก์มีหนังสือทวงถามแจ้งเรื่องอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไปยังจำเลย แม้จำเลยไม่ได้โต้แย้งแต่มิได้ตอบรับหรือแสดงเจตนากลับมายังโจทก์ว่ายินยอมให้โจทก์ใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าคู่สัญญาได้แสดงเจตนากำหนดเรื่องอัตราดอกเบี้ยไว้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิกำหนดอัตราดอกเบี้ยฝ่ายเดียว โจทก์คงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง นับแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2541 อันเป็นวันที่โจทก์ได้ชำระหนี้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

จำเลยร้องขอให้โจทก์ออกหนังสือประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือ Letter of Guarantee ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามข้อความที่จำเลยระบุในโทรพิมพ์และให้โจทก์แจ้งยืนยันไปยังจำเลยถึงการออกหนังสือประกันดังกล่าว ในโทรพิมพ์ฉบับนี้คงมีแต่ข้อความที่จำเลยขอให้โจทก์ออกหนังสือประกัน (Instructions) แต่ไม่มีข้อความที่จำเลยเสนอตอบแทนโจทก์ในการที่โจทก์ออกหนังสือประกันนั้นแต่อย่างใด โทรพิมพ์แผ่นที่ 2 มีข้อความว่า จำเลยให้อำนาจโจทก์เพิ่มข้อความสัญญาประกันช่วง (Counter Guarantee) ดังที่ระบุในโทรพิมพ์นี้เพื่อเป็นการตอบแทนที่โจทก์ออกหนังสือประกันให้ และโทรพิมพ์แผ่นที่ 3 จำเลยเพิ่มข้อตกลงตามที่ระบุในโทรพิมพ์ลงในสัญญาประกันช่วงต่อไปว่า ระยะเวลาการประกันช่วงจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อจำเลยได้รับโทรพิมพ์ที่ทดสอบแล้วจากโจทก์ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าเป็นคำสนองจากโจทก์นั้น ปรากฏว่าเป็นโทรพิมพ์ที่โจทก์ตอบกลับไปยังจำเลยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2537 สรุปใจความได้ว่า โจทก์ขอให้จำเลยเพิ่มข้อความลงในสัญญาประกันช่วงว่า เพื่อตอบแทนการที่โจทก์ออกหนังสือประกันให้แก่ผู้รับประกันจำเลยยอมผูกพันที่จะให้ค่าชดเชยแก่โจทก์ และให้ค้ำประกันโดยเพิกถอนไม่ได้ว่าจะชำระเงินให้แก่โจทก์ในโอกาสแรกเมื่อได้รับหนังสือทวงถาม (First Written Demand) โดยทางโทรพิมพ์ที่ทดสอบแล้ว (By Tested Telex) ระบุว่าโจทก์ถูกเรียกให้ชำระหนี้ตามหนังสือประกันของโจทก์เป็นจำนวนเงินที่ผู้รับประกันเรียกจริงตามที่จริง หากแต่ไม่เกินจำนวน... ดังนี้ ข้อความดังกล่าวแสดงว่าโจทก์ไม่ได้ตกลงรับว่าจะออกหนังสือประกันให้ตามที่จำเลยเสนอมาในทันที แต่โจทก์กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในคำสนองว่าโจทก์จะออกหนังสือประกันให้ตามที่ถูกร้องขอก็ต่อเมื่อจำเลยยอมประกันช่วงแก่โจทก์ว่าจำเลยจะชดใช้เงินตามจำนวนที่โจทก์ชำระให้แก่ผู้รับประกันคืนให้แก่โจทก์ เมื่อคำสนองดังกล่าวมีข้อความเพิ่ม

เดิม มีข้อจำกัด หรือมีข้อแก้ไขอย่างอื่นประกอบด้วย จึงถือว่าเป็นคำบอกปิดไม่รับ  
ทั้งมีผลเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 359  
วรรคสอง และเมื่อโทรพิมพ์มิใช่คำสนองรับจากโจทก์ แม้จำเลยได้รับโทรพิมพ์ดัง  
กล่าวที่ประเทศอิตาลี สัญญาขอให้ออกหนังสือประกันและสัญญาประกันช่วงระหว่าง  
โจทก์จำเลยก็ยังหาได้เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีดังที่จำเลยอ้างแต่อย่างใดไม่ ข้อเท็จ  
จริงฟังได้ต่อไปว่า เมื่อจำเลยได้รับโทรพิมพ์ดังกล่าวจากโจทก์ จำเลยมีโทรพิมพ์แผ่น  
ที่ 2 ตอบกลับมายังโจทก์ จำเลยให้อ่านาจอทก์ระบุข้อความรับผิดชอบในการประกันช่วง  
ดังกล่าวได้โดยจำเลยมิได้ขอให้มีความเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขอย่างใดอีก โทรพิมพ์  
ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำสนองของจำเลย ดังนี้ สัญญาขอให้ออกหนังสือประกัน  
และสัญญาประกันช่วงระหว่างโจทก์จำเลยย่อมเกิดขึ้นทันทีที่โจทก์ได้รับโทรพิมพ์ดัง  
กล่าวที่ประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 361 วรรคแรก  
จึงต้องใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่สัญญาเกิดคือกฎหมายไทยบังคับและต้องฟ้องต่อศาล  
ไทย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 มาตรา 13 ที่  
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจ  
ฟ้องนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นฟ้อง  
ด้วยในผล

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 65,840,499.52 บาท และจำนวน  
4,098,294.52 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินทั้งสอง  
จำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่  
โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 21 เมษายน 2543) มิให้เกิน  
22,403,808.33 บาท และมีให้เกิน 1,394,542.96 ดอลลาร์สหรัฐ ตามที่โจทก์ขอ กับ  
ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม  
50,000 บาท.

(อร่าม เสนามนตรี-สุวัฒน์ วรธนะหัย-พินิจ บุญชัด)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายชุมพล ภิญโญสิ  
นวัฒน์

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ